

1511091-62.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Magistrado: Thiago Baldani Gomes De Filippo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... a prática de outros crimes que lhe pudesse trazer renda, como o tráfico de drogas ou de armas.

Em outras palavras, a partir da descrição fática, todos os valores que seriam objeto de lavagem decorriam da exploração de jogos de azar e, reconhecida a ilegitimidade deste tipo contravencional, conseqüentemente não há se falar em configuração da lavagem como delito subsequente.

A par ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511091-62.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511091-62.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2110759/2020 - 04º DEL.CRIME C/FAZENDA, 7204512 - 04º DEL.CRIME C/FAZENDA, 2110759 - 04º DEL.CRIME C/FAZENDA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Baldani Gomes De Filippo

Vistos.

1. CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, em período até 17 de maio de 2019, porque teria dissimulado a origem, a movimentação e a propriedade de valores provenientes da contravenção penal de exploração de jogo de azar (art. 50 da Lei de Contravenções Penais), mediante a utilização de contas bancárias de interpostas pessoas ("laranjas"), a realização de diversas transações bancárias atípicas e a constituição de empresa de fachada, denominada "Cláudio Roberto dos Santos Serviços de Apoio Administrativo ME".

Recebida a denúncia (fls. 400/401), CLÁUDIO foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 550/552). Rejeitada esta, ratificou-se aludido recebimento (fls. 559/560).

Durante a instrução, foram ouvidas dez testemunhas. O acusado foi interrogado (fls. 783/786).

Ao cabo, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos moldes da denúncia (fls. 817/830). Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do réu, afirmando que, de fato, este praticou a infração penal do art. 50 da Lei de Contravenções Penais, porém que os valores percebidos por meio dessa prática eram reinseridos na manutenção da referida atividade, sem que houvesse um procedimento de transmutação aparente de verbas ilícitas em lícitas. Afirmou ainda que o patrimônio do réu é incompatível com a prática de lavagem de dinheiro e que constituiu sua empresa em momento diverso da exploração de jogos de azar. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a imposição de pena no patamar mínimo, afastada a continuidade delitiva e observada a primariedade do réu, além da fixação de regime inicial aberto, com possível substituição da pena privativa de liberdade (fls. 832/848).

É o relatório.

2.1. Em princípio, a despeito da relevância da matéria para o julgamento do presente feito, cabe sublinhar que não é o caso de se sobrestar o feito até o julgamento definitivo da questão acerca da compatibilidade do art. 50 do Decreto-lei 3.688/41 à Constituição da República pelo STF, na medida em que a decisão acerca da suspensão dos feitos que versam sobre a matéria sobre a qual foi reconhecida a existência de repercussão geral é de competência do relator do recurso extraordinário paradigma, como estabelece o § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, in verbis: “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”.

Ocorre, entretanto, em que pese a aparente cogência do dispositivo, o STF tem decidido que a suspensão do processamento dos demais feitos que versam sobre a matéria não é consequência automática do reconhecimento de sua repercussão geral. Decerto, a Suprema Corte já pontuou que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (STF, RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019).

Relativamente à questão acerca da compatibilidade do art. 50 do Decreto-lei 3.688/41 à Constituição da República, é certo que, em 03/11/2016, por maioria, o STF reconheceu a repercussão geral do tema (Tema 924 Recurso Extraordinário 966.177), ainda pendente de julgamento. Entretanto, relativamente a este caso, em específico, não houve determinação expressa por parte do Exmo. Min. Relator Luiz Fux de suspensão dos demais feitos sobre a matéria, inviabilizando-se que demais juízes e tribunais assim o fizessem, sob a pena de se conspurcar a competência exclusiva do relator do caso. Nessa direção, tem-se pontuado o seguinte: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

2. Considerando que o Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 979.962 RG, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há que se falar em suspensão automática do prazo prescricional. 3. Agravo

regimental desprovido.” (RE 1.013.001-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/4/2019).

Com isto, inviabiliza-se a suspensão do presente feito, impedindo-se a pretendida modulação dos efeitos decorrentes do reconhecimento da repercussão geral sobre o tema.

2.2. Quanto ao cerne, a ação penal não procede.

Como é sabido, para a configuração do crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 e imputado ao acusado, faz-se necessária a existência de infração penal anterior, uma vez que o processo de “lavagem” ocorre sobre bens ou valores obtidos ilicitamente e que, a partir da nova conduta criminosa, passam a integrar a economia formal de modo aparentemente regular. É o que se depreende da própria redação do dispositivo supracitado: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal” (grifei).

No caso dos autos, depreende-se da denúncia e de seu aditamento que os valores que supostamente passaram pelo processo de “lavagem” eram todos oriundos da prática do delito previsto no art. 50 do Decreto-lei 3.688/41. Ocorre, contudo, que a referida infração penal antecedente não supera os filtros ditados pelo princípio da proporcionalidade.

Assim, independentemente de qualquer análise sobre as provas produzidas nestes autos, impõe-se o desacolhimento da pretensão acusatória, porque a contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-lei 3.688/41 é constitucionalmente ilegítima, não tendo sido recepcionada pela ordem constitucional vigente.

Avulta a ilegitimidade desse tipo contravençional se contrastado com o princípio da proporcionalidade, o qual, malgrado a inexistência de sua previsão constitucional expressa, é incontestavelmente uma ferramenta valiosíssima para o exercício do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos.

Se, por um lado, a proporcionalidade é instrumento indispensável para a manutenção da harmonia do próprio texto constitucional e da investigação da coerência dos demais ramos jurídicos, por outro, sua baixa densidade normativa é deveras problemática. Visando a concretizá-la, a dogmática constitucional identificou e procurou desenvolver os seus três corolários: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Em linhas gerais, a adequação condiz com o controle da viabilidade de se atingir o fim pretendido por determinado meio; a necessidade refere-se à eleição do meio menos gravoso para a restrição; e a proporcionalidade em sentido estrito relaciona-se à demanda por equilíbrio entre o meio utilizado e o fim colimado, mediante análise de “custo-benefício”.

A grande questão que se coloca, no entanto, é de que maneira esses subprincípios podem sofrer uma releitura a partir da dogmática penal, a fim de que a proporcionalidade possua algum rendimento para a aferição da legitimidade dos tipos penais, em geral. A par dos diversos trabalhos acadêmicos que se ocupam do tema, é possível que o exame da adequação implique o estudo acerca dos interesses que podem ser adequadamente protegidos por meio do Direito Penal, vale dizer, de tudo aquilo que pode ser reconhecido como bem jurídico-penal; a investigação da necessidade restringe-se à análise das estruturas típicas utilizadas para a proteção penal de certo interesse, diante do princípio da ofensividade e do impedimento da criminalização de condutas que reflitam um rígido paternalismo penal; e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito diz respeito à perquirição em torno do equilíbrio das penas abstratamente cominadas pelo legislador penal, com fundamento no princípio constitucional da igualdade.

Colocadas essas necessárias premissas, a aferição da conduta contravençional de exploração de jogos de azar não supera os filtros da adequação e da necessidade, revelando-se desproporcional e, conseqüentemente, conduz à conclusão de sua não-recepção à atual ordem constitucional.

2.2.1. O tipo do art. 50 do Decreto-lei 3.688/41 é penalmente inadequado, porque ele não visa a tutelar um verdadeiro bem jurídico-penal.

Inicialmente, é importante sublinhar que, ao longo do tempo, as tentativas de estabelecer um conceito transcendente de bem jurídico-penal, que efetivamente

possua alguma possibilidade de forneça critérios limitadores do jus puniendi estatal, revelaram-se complexas e infrutíferas.

Sem embargo, há um feixe de interesses individuais, intimamente ligados ao postulado da dignidade da pessoa humana, tais como a vida, a integridade física, a liberdade e a propriedade, que poderão ser constantemente objeto de proteção penal. Por outro lado, também se revela em princípio adequada a tutela penal de interesses coletivos, tais como o meio ambiente, a confiança na segurança da moeda, a confiança na incorruptibilidade dos funcionários e os interesses que visam à preservação da estrutura funcional do Estado, como a administração da justiça, quanto em relação à arrecadação de recursos necessários para a realização de suas finalidades institucionais, como por exemplo, o sistema tributário. E, finalmente, também poderá se revelar adequada a utilização da intervenção jurídico-penal para a proteção dos chamados falsos bens jurídicos coletivos, porque representam simplesmente a soma dos vários bens jurídicos individuais, tais como a saúde pública, a paz pública, a segurança viária, dentre outros, desde que eles sejam funcionalizados e guardem referibilidade concreta à proteção desses mesmos interesses individuais.

Se há certa zona de penumbra acerca dos bens que podem ser classificados como bens jurídico-penais, é certo que alguns valores, absolutamente, não podem ser erigidos a essa categoria. O exemplo mais sintomático é a proteção de meras moralidades, matéria da qual não deve se ocupar o Direito Penal. Neste sentido, apresentava-se inadequada a criminalização do adultério (art. 240 do CP), abolida pela Lei 11.106/2005, porque a proteção da organização tradicional da família não deve ser assunto apto a ensejar a proteção penal. Pela mesma razão são discutíveis os tipos penais de ato obsceno (art. 233 do CP) e de escrito ou objeto obsceno (art. 234 do CP), porque a punição da pornografia entre adultos, em quaisquer de suas manifestações, reflete a pretensa proteção da moralidade e do pudor público. E, relativamente à contravenção de exploração de jogos de azar, o art. 50 do Decreto-lei 3.688/41 está inserido no Capítulo VII, do referido ato normativo, intitulado "Das contravenções relativas à polícia de costumes". Portanto, o seu objeto jurídico se resume aos bons costumes. Segundo Guilherme de Souza Nucci, "a ideia, ainda prevalente, é manter as pessoas afastadas desse tipo de jogo, que não depende de habilidade para ganhar (como, por exemplo, os jogos esportivos), mas de mera sorte. Essa situação pode levar à perda patrimonial, ao vício e aos desmandos de toda ordem".

Em sentido semelhante, o trabalho de Valdir Sznick assim sintetiza o fim de proteção dessa norma contravencional:

No jogo não só se visa a proteção ao trabalho honesto como a repressão ao ganho fácil. São conhecidos malefícios do jogo justamente pela ilusão de ganhos rápidos e sem muito esforço. Além das conhecidas consequências o jogo avilta, empobrece, degrada, pois leva o rico à pobreza e o pobre à miséria; e junto com a miséria o desamparo à família.

À inutilidade do jogo se contrapõe à sociabilidade do trabalho, mas tirando-se o azar e as apostas o jogo entre amigos e junto com a família é uma forma, senão saudável, pelo menos bastante utilizada e sem nenhum dano social.

Referidas preocupações, inobstante serem nobres e moralmente legítimas, não devem compor o feixe de interesses penalmente relevantes.

2.2.2. Ainda que, hipoteticamente, fosse possível se vislumbrar a proteção de um bem jurídico-penal pela norma em apreço, ou mesmo se se desacreditasse do potencial crítico conferido à teoria do bem jurídico, o tipo contravencional também não resiste a uma filtragem constitucional, igualmente à luz do princípio da proporcionalidade, mas sob o espreque da necessidade da proteção penal, porque ele reflete indevido paternalismo penal.

Em linhas gerais, como pontua Gerald Dworkin, o paternalismo pode ser compreendido como a "interferência sobre a liberdade de ação de alguém justificada por razões referentes exclusivamente ao bem-estar, ao benefício, à felicidade, às necessidades, aos interesses ou aos valores da pessoa coagida." O paternalismo penal, neste sentido, significa a utilização das leis penais para o alcance dessas mesmas finalidades.

Dentre suas classificações possíveis,, importa ao presente caso a sua distinção entre paternalismo rígido (hard) e paternalismo moderado (soft). Paternalismo rígido é aquele segundo o qual as leis buscam interferir nas escolhas dos indivíduos, indicando quais seriam os caminhos que melhor atenderiam aos seus próprios interesses, independentemente da capacidade de discernimento dos destinatários das normas, justificando-se, mesmo para sujeitos responsáveis, a proibição de autolesões e de heterolesões consentidas, como na hipótese de proibição de condutas masoquistas. Por outro lado, o paternalismo moderado justifica a interferência estatal quanto às escolhas eventualmente danosas aos próprios indivíduos, apenas quando não for possível se demonstrar a capacidade de discernimento destes, como no caso de crianças e sujeitos com doenças mentais. Inseridas no contexto paternalista, somente se justificam leis penais que retratam um moderado paternalismo, como se legitima, por exemplo, uma série de normas penais presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), independentemente da vontade desses sujeitos especiais.

Por outro giro, revelam-se absolutamente desnecessárias, logo, desproporcionais, leis penais que fletam com o paternalismo rígido, a saber, que visem à proteção de sujeitos imputáveis, autorresponsáveis, mediante a criminalização de comportamentos que lhes possam ser eventualmente danosos, a despeito de suas vontades e escolhas. A contravenção penal de exploração de jogos de azar nada mais revela do que a concretização de um indesejado paternalismo penal rígido, avultando-se, também por esta razão, a sua ilegitimidade.

2.2.3. Prestigiados doutrinadores, ainda que mediante outros argumentos, também defendem a ilegitimidade da contravenção em tela. Guilherme de Souza Nucci, por exemplo, defende sua desnecessidade pela invocação do princípio da intervenção mínima, não vislumbrando fundamento para a intervenção estatal na vida privada do cidadão que deseja se aventurar em jogos de azar, observando que seria correta a legalização dos jogos, porque inúmeros são aqueles patrocinados pelo próprio Estado, como as loterias em geral.

Em sentido semelhante, Katie Silene Cárceres Arguello sustenta ser uma grande hipocrisia haver jogos patrocinados pelo Estado, como as loterias federais e estaduais e, ao mesmo tempo, serem cominadas sanções penais aos jogos de azar, aduzindo que a prática é socialmente aceita e está arraigada nos costumes da sociedade.

E, por fim, Damásio de Jesus, de maneira específica no que tange à utilização de máquinas de diversão eletrônica adultos, como o caso presente, entendia que o fato é atípico, porque não constituiria propriamente jogo de azar, uma vez que “em seu manejo não interfere a sorte uma vez que está tudo previamente programado, e tampouco a habilidade do apostador, que se limita a apertar as teclas e esperar que a máquina apresente o programa preestabelecido”. E, alternativamente, Damásio fundamentava a atipicidade do fato em face da ausência de imputação objetiva de lesão a bem jurídico, observando estar implícita a eventual risco advindo da utilização das máquinas (teoria do risco tolerado), uma vez que o Estado admite a sua importação tributada.

Em sede jurisprudencial, a decisão que possibilitou o reconhecimento de repercussão geral da matéria é assim ementada:

“APELAÇÃO CRIME. JOGOS DE AZAR. ART. 50 DO DL 3.688/41. ATIPICIDADE. Conduta inserida no âmbito das liberdades individuais, enquanto direito constitucional intocável. Os fundamentos da proibição que embasaram o Decreto-Lei 9.215/46 não se coadunam com a principiologia constitucional vigente, que autoriza o controle da constitucionalidade em seus três aspectos: evidência, justificabilidade e intensidade. Ofensa, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da lesividade, que veda tanto a proteção insuficiente como a criminalização sem ofensividade. Por outro lado, é legítima a opção estatal, no plano administrativo, de não tornar legal a atividade, sem que tal opção alcance a esfera penal. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Crime 71006124234, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator Luis Gustavo Zanello Piccinin, j. 15/08/2016).

Em se tratando de jurisdição criminal, quando se trata de alargar os âmbitos da incriminação, não há espaço constitucional para graus de ativismos judiciais,

segundo a intangibilidade do princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5º, II e XXXIX, da Constituição, e no art. 1º do CP, o que justifica a proibição da analogia in malam partem. Todavia, em que pese o princípio da presunção relativa da constitucionalidade das leis, considerada a garantia da liberdade individual, justificada, inclusive, a analogia in bonam partem, é exigível do juiz criminal que escrute a legislação criminal à luz dos princípios e garantias fundamentais, que funcionam como limites intransigíveis a práticas estatais arbitrárias, recolocando-se a criminalização primária sob as trincheiras das diretrizes constitucionais. Nesses termos, a despeito de previsão constitucional expressa, é impositivo o exercício do controle de constitucionalidade, por via difusa ou incidental, sobre o art. 50 do Decreto-lei 3.688/41, reconhecendo-se a sua não recepção pela atual ordem constitucional.

2.3. Portanto, no que tange às imputações de lavagem de dinheiro, o seu exame depende da existência de infração penal antecedente.

Na hipótese, reconhecida a ilegitimidade da contravenção penal, automaticamente não há que se cogitar de acolhimento da pretensão acusatória, referente à prática de lavagem, nos termos art. 2º, § 1º, da Lei 9.613/98.

No caso, deve ser sublinhado que o único dinheiro que poderia ser objeto de lavagem, ao menos a partir da descrição fática da denúncia, tinha sua origem na exploração de jogos de azar, porque não se tem notícia que o acusado se valia do contexto criminoso para a prática de outros crimes que lhe pudesse trazer renda, como o tráfico de drogas ou de armas.

Em outras palavras, a partir da descrição fática, todos os valores que seriam objeto de lavagem decorriam da exploração de jogos de azar e, reconhecida a ilegitimidade deste tipo contravencional, consequentemente não há se falar em configuração da lavagem como delito subsequente.

A par desses argumentos, é o caso de desacolhimento da pretensão acusatória e consequente absolvição do acusado.

3. Em face do exposto, julgo improcedente a ação penal e absolvo CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 131, inciso III, do Código de Processo Penal, aguarde-se o eventual trânsito em julgado desta sentença absolutória para que se proceda à liberação dos bens sobre os quais recaem medidas constritivas decretadas por este Juízo.

Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA